
제59회 변리사 2차 시험

상표법 해설

안녕하십니까.

더위와 습기 찬 날씨가 반복되면서 심신이 지치셨을텐데, 이틀에 걸쳐서 시험을 무사히 치르시느라 정말 고생이 많으셨습니다!

시험 직후에 기출된 문제를 의도에 맞게 이해하고 해설을 해드리는 것은 상당히 부담이 되는 일이나, 상표법 때문에 마음이 복잡한 분들이 많으실 것 같아 상표법 해설 자료를 제공해 드립니다.

본 해설 자료는 주어진 사실관계와 설문의 문언 해석에 기초하되, 답안 구성의 효율을 위해 적절히 선해하여 작성되었음을 말씀드립니다.

코로나가 다시 성행하고 있는데 건강 유의하시고, 이 글을 보고 계신 분들의 합격을 기원합니다. 감사합니다!

(주)한빛지적소유권센터

상표법 강사 일동 배상

[문제-1]

I. 설문(1)

(1) 甲이 자신의 상표권에 기인하여 丙을 상대로 상표권침해금지를 주장하는 경우, 甲의 주장에 대하여 丙이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형 및 그 결과를 포함하여 상표법상 취할 수 있는 조치에 대하여 논하시오. (16점)

1. 무효심판

- (1) 法34조1항4호(해당 X)
- (2) 法34조1항6호(저명한 상호 - 오픈)
- (3) 法34조1항9호, 11호 내지 13호(해당 O)
- (4) 法34조1항20호(청문각判例 2020후10827 - 주논점)

2. 취소심판

- (1) 法119조1항1호 내지 5호, 7호 내지 9호(해당 X) - 간략 기재
- (2) 法119조1항6호(小)

3. 소극적 권리범위 확인심판(小)

COMMENT

1. 丙에게 포괄적으로 권리가 양도됨에 따라 BMKG를 영업의 출처로 사용함으로써 축적된 신용도 함께 이전이 되었다고 볼 수 있고, 이에 따라 “BMKG MAX”뿐만 아니라 “BMKG”도 丙의 저명한 상호로 볼 수도 있습니다.
2. 12호 후단을 기재할 때 SODA 판례를 언급할 수 있고, 후발적 무효사유 없음도 간략하게 언급 가능합니다.
3. 청문각 사건은 피고(문제1의 甲에 대응)과 소외인(문제1의 乙에 대응) 사이에 이루어진 계약이 상법상 “영업 양도”에 해당하는지에 관하여 원심과 상고심 사이에 다툼이 있었으나(상호와 관련된 채무를 인수 대상에서 제외하고 피고의 직원 중 일부를 새로 채용하기로 하는 내용 등에 따라 영업 양도가 성립하는지에 관하여 다툼이 존재), 문제1에서는 다툼의 여지가 있는 사실관계를 배제하였으므로 문제1은 명백히 “영업 양도”가 성립하는 것을 전제로 풀이를 해야 합니다.
4. 청문각 판례의 상고심에서 피고(문제1의 甲에 대응)는 “소외인(문제1의 乙에 대응) 또는 원고(문제1의 丙에 대응)”에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 판단할 뿐, 심판의 청구인인 원고(문제1의 丙에 대응)와의 관계에서 신의성실의 원칙에 반하는지를 별도로 언급하지 않은 것에 비추어보면 소외인과 원고 사이의 포괄 양수 계약에 의해 상표에 관한 권리가 이전되었는지 여부에 관하여는 판례도 명확히 하지 않았고 다툼의 여지가 있습니다. 다만, 실제 판례에서든 문제1에서든 적어도 소외인(문제1의 乙에 대응)과의 관계에서는 신의성실의 원칙에 반하는 것이 명백하고, 무효심판을 청구한 자가 소외인(문제1의 乙에 대응)이 아니어도 법률상 불이익이 있는 자면 청구인적격을 가질 수 있으므로, 청문각 판례에 기초하여 20호를 적용하는 것은 가능합니다.
5. 부정경쟁방지법 2조 1호 (파)목에 대응되는 사실관계가 주어진 것은 아니나, 설문(1)은 심판에 대한 조치를 다각적으로 묻는 문제로서, 119조 1항 6호도 작게나마 기재할 수 있습니다.
6. 소극적 권리범위 확인심판은 실효성이 떨어지나 조치 문제임을 감안하여 기재할 수 있으며, 권리범위 확인심판에서는 대인적 사유를 심리할 수 없음을 판례와 함께 간략히 언급하면서 선사용권을 녹여내는 것도 가능합니다.

II. 설문(2)

(2) 甲은 자신의 상표권을 무단 사용하고 있는 丁을 상대로 상표권침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 丁의 대응조치 및 소송의 결과에 대하여 논하시오. (6점)

1. 무효심결 확정 전의 조치

- (1) 문제의 소재 - 행정행위의 공정력(또는, 유효 추정의 원칙)
- (2) 권리남용의 항변(하이우드 判例 2010다103000)
 - 1) 법리 2) 사안 - 권리남용의 항변이 있는 경우에 한하여 심리
- (3) 소송절차 중지신청(法151조2항)

2. 무효심결 확정 후의 조치

- (1) 상표권 부존재 주장
- (2) 자유로운 사용

3. 소송의 결과 - 기각판결

III. 설문(3)

(3) 甲은 2022. 4. 15.(금) 자신의 등록상표 'BMKG' 에 대하여 戊와 독점적 통상사용권 사용계약을 체결하였다. 그 후 甲의 등록상표가 이해관계인의 무효심판청구에 의해 무효심결이 확정된 경우에 甲과 戊와의 법률관계 및 戊와 丁과의 법률관계에 대하여 설명하시오. (8점)

1. 甲-戊의 법률관계

- (1) 문제의 소재 / 戊의 사용권의 취급 (상표권 소멸에 부수하여 사용권 소멸)
- (2) 기지급 사용료 반환청구 (해당 X)
- (3) 미지급 사용료 지급청구 (해당 O)
- (4) 기타 민법상 책임에 따른 청구
 - 1) 계약상 책임 2) 하자담보책임 등

2. 戊-丁의 법률관계

- (1) 침해금지청구권의 직접행사 - 불가
- (2) 침해금지청구권의 대위행사 - 불가 (상표권 소멸에 따라)
- (3) 손해배상청구권의 행사 (제3자의 채권 침해 논리에 따라 행사 가능)

[문제-2]

I. 설문(1)

(1) 乙은 지정서비스업을 '요리업, 조리업' 으로 하여 표장 '마우미킹(MAUMIKING)' 을 2019. 3. 7.(목) 특허청에 상표등록출원을 하였고, 2019. 12. 16.(월) 상표등록을 받았다. 甲은 乙의 등록상표가 상표법 제34조제1항제13호에 해당한다는 이유로 상표법 제117조 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 이 심판의 결과에 대하여 논하시오. (8점)

1. 무효심판 의의, 취지

2. 法34조1항13호 해당여부

(1) 인식도 (문제에 주어짐)

(2) 상표의 유사 (해당 O)

(3) 부정한 목적 (각 간접사실 별로 포섭 多 중요)

1) 인식도, 창작성 2) 상표의 동일 유사성 3) 당사자의 관계 4) 사업을 실제로 준비했는지 여부 5) 상품의 동일 유사성

3. 설문의 해결 - 인용심결

II. 설문(2)

(2) 甲은 지정상품을 '주방용 기구' 로 하여 자신의 표장 'MAUMI' 를 2021. 2. 9.(화) 국내에 상표등록출원하였고, 2021. 12. 10.(금) 상표등록을 받았다. 甲은 2022. 1. 25.(화) 丙과 이 등록상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결하였다. 한편 丁은 음식 및 조리 분야 벤처창업자로 '주방용 기구' 를 지정상품으로 하고, 'MAUMI' 를 표장으로 하여 2021. 6. 8.(화) 상표등록출원을 하였고, 2022. 4. 8.(금) 상표등록을 받은 후, 자신의 등록상표가 부착된 지정상품을 제조하여 온라인에서 판매하고 있다. 丙이 丁에 대하여 취할 수 있는 상표법상 조치에 대하여 논하시오. (12점)

1. 침해인지 여부

(1) 문제점 (보호범위 내 사용 해당, 정당권원이 문제)

(2) 원고적격 유무 (해당 O)

1) 전용사용권 등록의 효력(法100조1항) 2) 제3자의 의미 判例 2017나2004

(3) 상표권의 저촉관계에 있어서 후출원등록상표의 사용이 침해인지여부

1) 학설 2) 종래 判例 3) 최근 전합 判例 2018다253444 4) 검토

(4) 소결

1) 저촉인지 여부(해당 O) 2) 침해인지 여부(해당 O)

2. 침해에 대한 조치

- (1) 민사상 조치 - 침손신부 (부당이득반환청구는 민법상 조치이나 넓은 의미에서 포함)
- (2) 형사상 조치 - 침몰양
- (3) 기타 조치 - 경고, (적극적 권리범위 확인심판은 권vs권이어서 불가 判例 언급 가능)

3. 등록에 대한 조치

- (1) 무효심판 (法34조1항7호, 法34조1항12호후단, 法34조1항13호)
- (2) 상표권의 양도, 포기 권유

COMMENT

1. 설문2를 문언적으로 해석하면 “사용에 대한 조치”와 “등록에 대한 조치”를 크게 나누는 것이 타당하나, 1) 설문1에서 “등록에 대한 조치”를 일부 논하여 “등록에 대한 조치”보다는 “사용에 대한 조치”를 주된 쟁점으로 물은 것이 출제의 의도로 보이고, 2) “사용에 대한 조치” 안에서도 상표, 상품이 동일하여 보호범위 판단이 필요가 없으므로 사실상 데이터 팩토리 判例를 주된 쟁점으로 쓸 수 밖에 없는 점을 고려하여, 데이터 팩토리 判例를 주쟁점으로 하여 침해여부를 판단하고 그 이후에 침해를 전제로 하는 “사용에 대한 조치” 및 침해와는 별개이나 중요도가 다소 낮다고 볼 수 있는 “등록에 대한 조치”를 병렬적으로 기재하는 것이 좀 더 매끄러울 것으로 보입니다.
2. “등록에 대한 조치”에서 法34조1항7호는 “저촉인지 여부” 판단과 동일하므로 간단하게 포섭하고, 法34조1항12호후단은 특출인이 주어져 있고 상표, 상품이 동일하여 결론이 쉽게 내려지므로 마찬가지로 간단하게 포섭하고, 法34조1항13호는 설문(1)과 판단이 크게 다르지 않아 마찬가지로 간단하게 포섭할 수 있습니다.

[문제-3]

I. 설문(1)

(1) 상표의 보통명칭화의 의미 및 이에 대한 판단기준에 대하여 설명하시오. (10점)
--

1. 보통명칭화의 의미

- (1) 보통명칭 및 보통명칭화의 의미
- (2) 보통명칭화 유형
- (3) 보통명칭화 방지책

2. 보통명칭화의 판단기준

- (1) 주체적, 시기적, 객체적, 지역적 기준
- (2) 관련 判例 2005도5358 (신중하게 판단하여야 한다)

II. 설문(2)

(2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 논하시오. (10점)

1. 출원에 대한 조치

(1) 이의신청, 정보제공

1) 法34조1항4호(해당 X) 2) 法34조1항9호, 11호 내지 13호(결론 옳)

(2) 출원의 취하, 포기 권유 (거절이유 없다고 하더라도 예비적으로 기재)

2. 사용에 대한 조치

(1) 침해인지 여부 (결론 옳)

(2) 침해에 대한 조치 (침해가 아니라고 하더라도 예비적으로 기재)

COMMENT

1. 乙의 출원상표는 X에 乙의 다른 등록상표가 K가 부착되어 있고 K가 “등록상표”라고 명시한 것은 K가 식별력이 있는 부분임을 의도한 것으로 파악되어, 乙의 출원상표에는 法33조1항1호의 거절이유는 없어보입니다.
2. “甲이 취할 수 있는 조치”를 물었으므로 저명상표임을 전제로 法34조1항9호, 11호 내지 13호가 적용된다고 기재할 수도 있고, 문제 사실관계에 기반하여 보통명칭이므로 法34조1항9호, 11호 내지 13호는 적용될 수 없다고 기재할 수도 있습니다. 문제에 주어져 있는 사실관계만으로는 보통명칭/저명상표 중 어느 것에 해당하는지 단정할 수 없으므로 문제2의 설문(2)는 결론이 옳은 문제로 보입니다.

III. 설문(3)

(3) 위 (2)의 甲의 조치에 대하여 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 대응조치에 대하여 논하시오. (10점)

1. 이의신청에 대한 조치 - 답변서

甲 상표가 보통명칭화 되었으므로, 양 상표가 비유사함을 주장

2. 침해조치에 대응한 조치 - 소송상 주장

(1) 보통명칭화를 전제로 상표 비유사 주장

(2) 法90조1항2호 효력제한의 항변

(3) 권리남용의 항변 - 하이우드 判例 2010다103000 (후발적으로 法33조1항1호 해당)

[문제-4]

I. 설문(1)

(1) 심사관이 거절결정 전에 甲에게 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 것에 대한 위법성 여부를 논하시오. (7점)

1. 문제의 소재 / 法55조1항의 의의
2. 法55조1항의 효력 - 강행규정 判例 2017후1779
3. 설문의 해결 - 위법

II. 설문(2)

(2) 심결취소소송에서 乙은 “X상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 전사용상표 Z와 유사하고, A서비스업과 C서비스업은 경제적 관련성이 있어 상표법 제34조제1항제12호에 해당한다.” 고 주장하였다. 심결취소소송의 법원이 乙의 주장을 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있는지 논하시오. (13점)

1. 문제의 소재 / 심결취소소송의 의의, 취지
2. 참가 적부 (관련 判例 - 2012후1033)
3. 심결취소소송의 심리범위
 - (1) 학설
 - (2) 判例
 - (3) 검토
4. 관련 判例 2015후1997
5. 설문의 해결 - 적극